

1515803-12.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/03/2022

... sobre sequestro. Cyntia admitiu que atuava no tráfico da região. Ela apontou onde morava e franqueou a entrada na residência. Com a ajuda do canil, localizaram drogas, anotações de tráfico, dinheiro e munições de calibre ponto 40 e ponto 30. O corréu também confessou participar do tráfico e era funcionário de Cyntia. A ré morava próximo à Rua das Taboas. A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1515803-12.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515803-12.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2174896/2021 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 18765138 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 3497/21/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2174896 - 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CYNTIA RAMOS FONTES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

CYNTIA RAMOS FONTES e JOSÉ MARCOS DA SILVA FILHO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, acusados de, no dia 28.06.2021, por volta das 11.30 horas, na Rua das Taboas, n. 63, viela, Campo Limpo, nesta cidade e comarca, de comum acordo, terem em depósito e manterem sob sua guarda, para fins de tráfico e fornecimento a terceiros, cerca de 1.745 (mil setecentos e quarenta e cinco) porções da substância vulgarmente conhecida por 'maconha', num total de 9.753,9g, uma sacola contendo cigarros artesanais de 'maconha' parcialmente queimados, pesando cerca e 22.7g, 3 (três) adesivos/selos contendo "LSD", num total de 0,04g, 2 (dois) comprimidos de ecstasy,

num total de 0,8g, 1.462 (mil quatrocentos e sessenta e dois) porções de cocaína, num total de 715,9g, e 4 (quatro) sacos contendo cocaína a granel, num total de 1.767,8g, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Laudo de constatação de fls. 62/66.

Consta, ainda, do incluso inquérito policial que, no dia 28.06.2021, por volta das 11.30 horas, na Rua das Taboas, n. 63, viela, Campo Limpo, nesta cidade e comarca, CYNTHIA RAMOS FONTES, qualificada nos autos (fls. 17), mantinha sob guarda, depósito e ocultava 11 (onze) cartuchos íntegros, sendo 10 (dez) calibre .40 e 1 (um) calibre .30mm, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais militares dirigiram-se até o local dos fatos, tendo em vista a notícia irradiada via COPOM sobre ocorrência de "sequestro e cárcere privado". Ocorre que no local dos fatos (uma viela) os policiais se depararam com os denunciados, CYNTHIA e JOSÉ MARCOS, em atitude suspeita, pessoas que possuíam as mesmas características fornecidas na 'denúncia' e que, ao vê-los, dispensaram apressadamente num bueiro ali existente o cigarro de 'maconha' que juntos consumiam, resolvendo abordá-los. Em revista pessoal, junto aos denunciados, nada de ilícito foi apreendido; indagados sobre eventual ocorrência de sequestro e cárcere privado no local, negaram suas participações, mas admitiram envolvimento na prática de tráfico de drogas, instante em que a denunciada CYNTHIA, então, apontou a casa situada ali próximo, a qual declarou residir.

E foi assim que, em diligência, os policiais dirigiram-se até a residência da denunciada Cynthia e, diante do odor de entorpecentes presente no imóvel detectado pelos cães farejadores, após ser franqueada a entrada naquela habitação, os policiais localizaram a estupenda quantidade de drogas (1.745 porções de 'maconha', 1 sacola contendo inúmeros cigarros artesanais de 'maconha', aparentemente estarem parcialmente queimados, 3 adesivos de "LSD", 2 comprimidos de ecstasy, e 1.462 porções de cocaína, mais 1.767,8g da mesma substância), acima referida, que estava pronta para ser comercializada. Cerca de R\$ 12.778,00 em espécie, provenientes do tráfico, mais invólucros plásticos (cerca 3.140), utilizados para embalar as drogas, duas balanças 'de precisão', e papel com as anotações referentes à contabilidade do tráfico, foram apreendidos no local, além de 10 (dez) cartuchos íntegros do calibre .40, 1 (um) calibre .30MM, e duas mochilas, uma sacola, um laptop, três facas, e uma caixa de isopor, de origem duvidosa, sem que a denunciada possuísse a devida autorização para portar tais munições.

As drogas foram apreendidas (fls. 27/29 e fls. 30/32) e examinadas, resultando positivo para 'maconha', 'crack' e cocaína, conforme Laudo de Constatação (fls. 62/66). Indagados a respeito, os denunciados admitiram informalmente a prática do tráfico de drogas, tendo José Marcos confessado no calor dos acontecimentos que era "empregado" da denunciada.

A denúncia foi recebida no dia 07 de julho de 2021, oportunidade em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 248/253).

Citados, os réus apresentaram resposta à acusação a fls. 285/314, rejeitada pela decisão de fls. 323/327, que também afastou a matéria preliminar.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo os réus interrogados.

Em alegações finais, o Ministério Público postulou a condenação dos acusados, nos exatos termos da denúncia (fls. 483/502).

A Defesa do réu Jose Marcos da Silva Filho requereu preliminarmente: a inexistência de fundada suspeita para ingresso na residência da acusada, violação do domicílio e contaminação da prova na origem (teoria dos frutos da árvore envenenada), inépcia da inicial, na instrução violação do cross examination. No mérito requer a absolvição do réu por falta de provas, crime impossível, erro de tipo.

Subsidiariamente, aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, detração, regime inicial aberto, direito de apelar em liberdade (fls. 504/546).

A Defesa da ré Cynthia requereu a absolvição da acusada, na forma do artigo 386, inciso VII, do CPP, ante a insuficiência do conjunto probatório. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena base no mínimo legal, a aplicação do § 4º do artigo 33

da Lei de Drogas, a aplicação do artigo 41 da referida Lei, fixação do regime aberto e substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, direito de recolher em liberdade e prisão domiciliar da ré (fls. 554/575).

É o relatório.
Fundamento e Decido.

Das Preliminares

Alega a defesa, em apertada síntese, que no caso dos autos, os policiais teriam invadido o domicílio da ré, em afronta ao artigo 5º, inciso XI da Constituição Federal, uma vez que não comprovaram o livre consentimento da ré para ingresso em sua residência. Aduz, também, que os policiais não demonstraram a existência de fundada suspeita que ensejasse o ingresso em sua residência.

Em que pese o alegado pela defesa, o entendimento fixado no precedente do HC 598.051/SP fora anulado no tocante à necessidade de gravação audiovisual e registro escrito do morador, nos termos do decidido no RE 1.342.077/SP, Min. Rel. Alexandre de Moraes, julgado em 02/12/2021.

O STJ, quando do julgamento do HC 598.051/SP sobrepujou suas funções, violando a separação de poderes (artigo 2º da Constituição Federal), e ao exigir a gravação do consentimento do morador, ou registro escrito de consentimento inovou na ordem jurídica, atuando como legislador.

Neste sentido:

(...) o Tribunal da Cidadania extrapolou sua competência jurisdicional, pois sua decisão, não só desrespeitou os requisitos constitucionais previstos no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, restringindo as exceções à inviolabilidade domiciliar, como também, inovando em matéria constitucional, criou uma nova exigência – gravação audiovisual da anuência de entrada no local – para a plena efetividade dessa garantia individual, desrespeitando o decidido por essa SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral.

Em que pese a boa vontade e a sólida fundamentação em defesa dos direitos e garantias fundamentais, o Superior Tribunal de Justiça inovou no exercício de sua função jurisdicional, acrescentando ao inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal um requisito não previsto pelo legislador constituinte originário.

(...)

Ao impor uma específica e determinada obrigação à Administração Pública, não prevista no inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça não observou os preceitos básicos definidos no artigo 2º do texto maior, que consagram a independência e harmonia entre os Poderes e garantem que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade (RE 636.686-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013; RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009).

(...)

Assim atuando, o Superior Tribunal de Justiça tornou conflituosa a relação entre o juiz e o legislador e desrespeitou, no exercício da interpretação, uma importante expressão restritiva do poder dos juízes enunciada pelo JUSTICE HOLMES, em 1917: "os juízes fazem e devem fazer obra legislativa, mas se nos interstícios da lei: não movem massas, mas somente moléculas" (Southern Pacific Co. v. Jensen, diss. Op. 244 US 205, 221 – 1917). Incabível, portanto, na presente hipótese e em sede de habeas corpus individual, ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo o aparelhamento de suas polícias, assim como o treinamento de seu efetivo e a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca domiciliar, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência, em que pese

inexistir tais requisitos no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, nem tampouco no Tema 280 de Repercussão Geral julgado por essa SUPREMA CORTE. Diante de todo o exposto, em face do decidido no Tema 280 de Repercussão Geral, CONHEÇO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO E ANULAR O ACÓRDÃO RECORRIDO tão somente na parte em que entendeu pela necessidade de documentação e registro audiovisual das diligências policiais, determinando a implementação de medidas aos órgãos de segurança pública de todas as unidades da federação.

Ora, o comando constitucional que assegura a inviolabilidade do domicílio elenca exceções, entre elas, o flagrante delito, que excepciona a tal garantia tanto durante o dia quanto durante à noite.

Neste sentido foi o entendimento do Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.342.077: O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante.

A situação flagrancial, como é a dos autos, dispensa o consentimento do morador para que haja o ingresso na residência. De fato, os policiais receberam a denúncia anônima de sequestro e receberam descrições de um rapaz e uma mulher, de prenome Cyntia, que estariam envolvidos em tal delito. A descrição coincidia com a dos acusados, circunstância que ensejou a abordagem.

Assim, os policiais relataram que a acusada consentiu no ingresso dos policiais em sua residência.

Observe que, segundo o depoimento dos policiais, houve gravação realizada pelos policiais do suposto consentimento declarado pela acusada que não foi juntado nos autos, mesmo depois de diligência requerida após o término da instrução processual. Ora, tal consentimento se mostra dispensável, uma vez que havia justa causa para o ingresso da Polícia na residência consubstanciada na ação do canil que sinalizou que havia entorpecentes dentro do local em questão. Cabe frisar que a situação flagrancial era evidente, uma vez que o delito de tráfico é de crime permanente. Assim, a ausência da mídia com o consentimento da acusada em nada altera o quadro probatório e a atuação dos policiais, tendo sido suprida pela justa causa devidamente demonstrada, como acima exposto.

Destarte, afasto as preliminares de ausência de consentimento da moradora para ingresso da polícia, em razão da situação flagrancial, bem como a preliminar de falta de justa causa para o ingresso na residência, e inviolabilidade de domicílio. Com relação à violação do exame cruzado (cross examination) durante a instrução processual, observo que se trata de nulidade relativa, que deveria ter sido alegada quando da realização do ato, estando, portanto, preclusa.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. IMPRESCINDIBILIDADE. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO CONFIGURADO PREJUÍZO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - A não observância da regra do art. 212 do CPP, por se tratar de nulidade relativa, exige a arguição no momento oportuno, sob pena de preclusão, bem assim a comprovação do alegado prejuízo, conforme o princípio do pas de nullité sans grief.

Precedentes.

III - In casu, a Defesa deixou de arguir a nulidade apontada em momento oportuno, isto é, durante a própria audiência de instrução e julgamento. Logo, ocorreu a preclusão consumativa da matéria.

IV - Além disso, a impetração limitou-se a arguir de forma genérica e superficial a suposta nulidade do ato, deixando de apontar e demonstrar a ocorrência de prejuízo. Habeas corpus não conhecido (HC 472.118/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 06/11/2018).

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito.

Do mérito - Ré Cyntia

No mérito e em relação à ré Cyntia, a pretensão penal é procedente em parte.

A materialidade dos crimes está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, no boletim de ocorrência (fls. 03/08), nos autos de exibição e apreensão (fls. 27/29 e 30/32), no laudo de constatação (fls. 62/66) e no laudo de exame químico toxicológico (fls. 317/320), que resultou positivo para tetrahydrocannabinol, 2C-E, metilenodioximetanfetamina (MDMA), e cocaína, pelo laudo de balística das munições apreendidas (fls. 352/355), bem como pelos demais laudos periciais juntados (fls. 330/333, 334/339, 340/343, 344/346, 347/349, 350/351) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria de Cyntia, igualmente, restou demonstrada.

Em solo policial, a ré permaneceu silente e o corréu negou a autoria delitiva (fls. 19).

Em juízo, a ré Cyntia declara que estava passeando na favela no dia dos fatos, pois conhece alguns moradores da comunidade, e encontrava-se desempregada. Estava conversando com algumas pessoas, quando uma viatura chegou e a selecionou junto do corréu JOSÉ, tendo sido colocados em frente a um portão. Olharam os celulares e nada encontraram. Perguntaram sobre drogas e armas, mas negou que soubesse de algo; Perguntaram onde a ré morava, pelo que respondeu que no morro verde com seu filho e sua mãe. Uma viatura do canil chegou e disseram que iriam encontrar o local com drogas. Subiram um escadão e, após, pegaram-lhe e disseram que foi arrogante. Estavam com algum objeto e disseram que era de sua propriedade. Foi ameaçada a todo momento pelos policiais e disse que não sabia de nada. Outros policiais disseram que seria levada, pois não colaborou com eles. O corréu também foi detido. Não sabe como encontraram a casa. Não portava nenhum cigarro de maconha. Fumava somente cigarros convencionais. O pai do réu José Marcos apareceu no local, mas não pode se aproximar de seu filho. Não sabe com o que o corréu trabalhava. As outras pessoas inicialmente abordadas foram liberadas.

Em sede policial o réu José Marcos negou que trabalhasse com Cynthia; disse que a conhece da viela onde moram. Relatou que a viu na comunidade e sentou-se ao seu lado e fumaram um baseado juntos. Pouco tempo depois chegaram policiais militares, ao passo que o réu dispensou o cigarro de maconha. Foi firme em negar que trabalhe com o tráfico. Negou que os policiais tenham falado algo sobre cárcere privado. Disse que não confessou que trabalha com Cynthia. Afirmou que trabalha com seu pai pintando casas. Foi interrogado na companhia de seu advogado (fls. 20).

Em Juízo, o réu JOSÉ MARCOS declarou que estava conversando com a ré CYNTIA e outras pessoas, comentando sobre a morte do serial killer Lázaro. Um policial chegou e apontou uma arma em sua cabeça, perguntando se tinha drogas, pelo que negou; perguntou onde era a casa, sendo que também não sabia; perguntou qual era sua ocupação, e disse que era ajudante de pintor juntamente com seu pai. Ainda, o policial fez outras perguntas para a Cyntia e saiu com ela e subiram o escadão. Relatou que sua irmã lhe levou uma garrafa de água, mas o policial não deixou tomar. Posteriormente, trouxeram uma blusa, mas também não o deixaram vesti-la. Disse que a patroa de sua mãe estava lá e perguntou aos policiais sobre a situação de José, pelo que o policial respondeu que era mera abordagem de rotina e que logo seria liberado. Os policiais lhe perguntaram se não havia nada de ilícito em sua casa, pelo que o réu respondeu que não e que poderiam entrar em sua casa para constatar tal fato. Foi levado para a viatura e chorou, dizendo que é trabalhador.

Não foi em nenhuma casa. Não sabe se Cyntia mora no local. É casado, mas não tem filhos. Nunca foi processado e nunca mexeu com nada de errado. Já trabalhou no Burger King. Completou o ensino médio. Não viu Cyntia confessando o cometimento do crime. A abordagem terminou por volta das 18h.

O policial militar Julio Cesar da Costa Oliveira, em Juízo, relatou que estavam em patrulhamento pela região dos fatos, sendo que o COPOM informou, com base em denúncia anônima, sobre ocorrência de sequestro e cárcere privado, relatando os nomes, as características físicas dos suspeitos (em especial as tatuagens que condiziam com as de Cynthia), e as vestimentas. Foram ao local e visualizaram os réus fazendo uso de entorpecentes. Abordaram-nos e as características condiziam com as da denúncia. Eles não relataram nada sobre sequestro. Cyntia admitiu que atuava no tráfico da região. Ela apontou onde morava e franqueou a entrada na residência. Com a ajuda do canil, localizaram drogas, anotações de tráfico, dinheiro e munições de calibre ponto 40 e ponto 30. O corréu também confessou participar do tráfico e era funcionário de Cyntia. A ré morava próximo à Rua das Taboas. A residência era habitável, sendo que havia roupas e móveis. Não apreenderam a droga que eles usavam. Não conheciam os réus. Não estavam utilizando bodycam da polícia, que à época dos fatos não estavam à disposição dos policiais. Não havia policial feminina para abordar a ré. Questionado por que não arrolou testemunha entranha aos quadros policiais respondeu que não houve necessidade. Na abordagem nada de ilícito foi encontrado com os réus. Gravaram a ré confessando a autoria delitiva em um celular e autorizando a entrada na casa. Questionado se repassou a gravação à autoridade policial, respondeu que esta não solicitou as imagens (fls. 366).

No mesmo sentido o depoimento do policial militar Felipe Gonçalves da Silva, que ratificou que abordaram os réus após denúncia de sequestro, via COPOM, sobre uma mulher chamada Cyntia e um homem com camiseta branca e uma tatuagem de palhaço no braço. Eles faziam uso de droga, mas a dispensaram em um bueiro. Em revista pessoal - realizada pelo depoente - nada de ilícito foi encontrado com eles, mas a ré admitiu que fazia parte do tráfico de drogas da região, tendo indicado onde ficava a sua residência. Solicitaram apoio do canil e foram até a casa da ré, após ela autorizar a entrada. Encontraram drogas, dinheiro e munição na residência.

Questionada sobre a munição encontrada, disse que recebeu de alguns amigos e guardava na casa. O corréu disse que trabalhava para Cyntia. Fizeram um vídeo da acusada autorizando a entrada. A casa era próxima ao local onde foram abordados. Havia R\$ 12.000,00, notebooks e cadernos com anotações do tráfico, celular, balança de precisão, eppendorfs vazios e a droga. O apoio chegou em pouco tempo.

Posteriormente, familiares do réu José apareceram e reclamaram da abordagem (fls. 367).

A testemunha Elisabete Leoncio, em Juízo, disse que a mãe do réu trabalha em sua residência. No dia dos fatos, foi levar uma cesta básica para mãe do réu e visualizou a abordagem da polícia. Ao questionar os policiais, responderam que se tratava apenas de uma averiguação. Eles moram em uma comunidade perto de sua residência. Não conhece a ré Cyntia. Disse que pelos relatos da mãe de José, este nunca teve problemas com a polícia e trabalha com o pai como pintor e pedreiro. Após, a polícia levou Marcos para a delegacia e foram até lá também. O policial disse para o réu admitir que trabalha no tráfico, de modo que ele admitiu. Acredita que ele foi coagido. O local da abordagem era dentro da comunidade e havia comércio. Disse que a mãe do réu nunca comentou se ele é usuário de drogas. O réu não estava algemado quando chegou. Não havia policial feminina escoltando a ré. Não pode afirmar se havia drogas com os réus. Disse, também, que foi empurrada e levaram o réu embora. Trabalha na área comercial do Carrefour. Não se recorda qual dia da semana aconteceram os fatos. O policial Felipe era moreno com o cabelo curto (fls. 368).

A testemunha de defesa Maiara Sabino Cordeiro, em Juízo, disse que conhece o réu JOSÉ somente de vista e que mora no local há 30 anos, desde que nasceu. O pai dele já prestou serviços próximos à sua casa, assim como o acusado. No dia dos fatos, presenciou a abordagem policial, por volta das 11h30 por estar passando pelos fatos e conversando com uma vizinha. Não soube o motivo da abordagem e os policiais não permitiram que ninguém se aproximasse. Não estava trabalhando no dia dos fatos. Não

viu nada na posse dos réus. Não sabe o motivo da prisão. O réu estava com as mãos para trás o tempo todo. Disse que tentou conversar com os policiais para entender o que estava acontecendo, mas os policiais pediram para que ela se afastasse. Relatou que esse tipo de operação policial é rotineira na comunidade. Posteriormente, chegaram policiais com cachorros. Informou que não permitiram que os réus falassem com familiares e advogados. Não viu a polícia militar com drogas, armas e munições. Acredita que os fatos se deram em uma segunda-feira. Não conhece Cyntia (fls. 369). A testemunha de defesa Regina Célia Ribeiro, em Juízo, relatou que mora há 22 anos na mesma comunidade dos réus. Relatou que é líder comunitária. No dia da prisão deles, estava com sua filha vendo uma casa, quando avistou uma viatura, sendo que os policiais pararam e foram para cima do réu JOSÉ, que estava parado e conversando normalmente com a sua filha de 26 anos, grávida de 8 meses. A ré CYNTIA também estava conversando. Havia mais pessoas próximas. Disse que os policiais agiram com brutalidade e mandaram o José levantar. Ordenaram que os acusados levantassem as mãos e, após, os levaram para outro lugar. Não conhece tanto a ré CYNTIA, pois ela tem mais amizade com sua filha. Disse que sua filha que estava grávida foi empurrada por um policial e quase caiu no chão. Após a família do réu chegar, a depoente se retirou, por volta das 11h30. Os fatos se deram por volta das 11h da manhã. Não lembra muito bem do policial que empurrou sua filha grávida. Não foi abordada por nenhum policial. Não havia policial feminina participando da operação. A PM faz operações frequentes na comunidade e que sofrem com a opressão deles. Os policiais não autorizaram que os réus ligassem para algum advogado (fls. 384). A testemunha de defesa Daiana Oliveira Rocha, em Juízo, disse que conhece apenas o réu JOSÉ MARCOS pois já contratou os serviços de seu pai em julho de 2021, sendo o acusado seu ajudante. Disse que na data dos fatos foi levar seu filho para pegar a perua escolar, por volta das 11h00, 11h30 e viu José Marcos sentado do lado da acusada. Viu a prisão do réu, após uma viatura entrar na comunidade e abordá-lo. Não ouviu o que os policiais disseram. Levaram-nos até o portão de uma garagem e foram abordados juntamente. Ao final da tarde, subiram com JOSÉ MARCOS no escadão. Ficou lá todo esse tempo em razão de saber que ele é uma pessoa trabalhadora. Nada de ilegal foi encontrado com ele. Trabalha em uma churrascaria e estava de folga no dia. Nem almoçou no dia. Nunca ouviu nada de ruim sobre os acusados. Não havia policial feminina na operação. Disse que as abordagens policiais na comunidade são rotineiras e que sofrem com a opressão policial. Os réus foram tratados de forma desumana e nem puderam beber água (fls. 385). A testemunha de defesa Roseane Lima da Silva, em Juízo, disse não conhecer os réus. Presenciou a chegada da polícia e parte da abordagem, que ocorreu na frente de sua casa, por volta das 11h30. Os réus e mais quatro pessoas estavam apenas conversando, quando a polícia chegou. Outras pessoas próximas não foram abordadas. Primeiro abordaram o réu e depois a ré. Nada de ilícito foi encontrado com eles. Em dado momento, por volta das 14h30, desceu de sua sacada e perguntou para os policiais o que os réus fizeram de errado. Responderam-lhe que se tratava de abordagem de rotina. Tentou fornecer água para eles, mas foi impedida. Não havia nenhuma policial mulher na operação. Tentou subir o escadão para acompanhar, mas só subiu até a metade onde havia uma barreira de policiais. Soube que foram levados em uma casa, mas não sabe o que ocorreu. Soube que a ré não mora na comunidade, mas já a viu na comunidade de final de semana. Disse que o réu trabalha como pintor. O pai do acusado chegou ao local posteriormente. Não trabalhou no dia dos fatos, pois está de licença após ter feito uma cirurgia. Nunca havia visto uma operação policial tão demorada como essa na comunidade, que se estendeu até depois das 17h. Disse que a primeira equipe que os abordou não agiu com violência. Mas a segunda equipe, que chegou com os cachorros, agiram com truculência mas não com os réus e sim com a depoente (fls. 386). A testemunha de defesa Jessica Oliveira Sampaio, em Juízo, aduziu que é moradora da comunidade, que estava presente no dia dos fatos e que conhece os réus apenas de vista. Eles estavam na rua conversando juntamente de outras pessoas, enquanto a depoente passeava com seu cachorro. Os policiais chegaram a pé, e depois veio o camburão. Os policiais chegaram com armas e abordaram os acusados, primeiro o José Marcos, depois a Cyntia. Eles ficaram no local por bastante tempo. Os policiais

disseram que era uma abordagem normal. Subiram com eles em um escadão por volta das 17h. Não sabe se a polícia os levou para alguma casa. Nada de ilícito foi encontrado com eles. Acredita que o réu trabalha como pintor. Conhece o pai dele de vista. Nunca havia visto os policiais em outra abordagem. Ao questionar os policiais sobre a situação dos réus disseram que os soltariam, mas bloquearam o acesso do escadão e levaram os réus para a Delegacia sem maiores explicações. Relatou que a polícia age com brutalidade na comunidade e que presenciou a ação até o final da operação. Não avistou nenhum policial com drogas ou armas. Não havia policial feminina na operação (fls. 387).

Essas foram as provas orais produzidas.

A condenação da ré Cyntia pelo delito de tráfico é medida de rigor.

O conjunto probatório permite concluir que o local onde a droga e as munições foram encontradas era, de fato, sua residência, como é possível constatar do interrogatório do réu em sede policial, acompanhado de advogado (fls. 20). Disse que conhece Cyntia da mesma viela onde moram. Em que pese a negativa da ré que o local da apreensão das drogas fosse sua residência, sequer juntou comprovante de residência nos autos.

Cumprir dizer que o depoimento de policiais tem valor jurídico idêntico ao de outras testemunhas estranhas aos quadros da corporação, sendo totalmente descabido e inconsequente o preconceito acerca dos seus depoimentos. Na verdade, inexiste qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos judiciais que sejam prestados por policiais. A circunstância de serem agentes públicos não os torna suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um Juízo antecipado e genérico sobre o depoimento, de sorte a reduzir-lhe, "a priori", o poder de convencimento. Com efeito: "São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha." (STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 07/03/2017, DJe de 14/03/2017).

Com efeito: "São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha." (STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 07/03/2017, DJe de 14/03/2017).

Consoante se infere dos depoimentos colhidos, não pairam dúvidas de que a ré praticou os delitos descritos na denúncia, basta ver a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas em seu poder, previamente embaladas para a venda a terceiros, além de sua variedade e dinheiro, tudo a revelar o intuito de comercialização. A condenação pelo tráfico de drogas não reclama a identificação do fornecedor ou do comprador, nem mesmo se exige a prova da efetiva ocorrência do ato de mercancia. Trata-se de tipo misto alternativo, cuja conduta dos réus se ajustou às modalidades "trazer consigo", "guardar", "ter em depósito". Ademais, os policiais não conheciam os réus anteriormente e não havia motivo plausível para incriminá-los por mero capricho.

O delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 não possui elemento subjetivo do tipo ou o chamado dolo específico, pois este "aparece apenas no art. 28, de forma que, sendo exclusivamente o porte, a guarda ou a compra, para consumo pessoal, é determinada a aplicação de penas restritivas de direito especialmente previstas em lei. Qualquer outra finalidade do agente determina a incidência do art. 33, inclusive a distribuição gratuita" (VICENTE GRECO FILHO, Tóxicos, Prevenção e Repressão, Saraiva, 13ª edição, págs. 150/151).

O crime de tráfico de drogas, tal como concebido na legislação brasileira, não pressupõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização (STF, HC nº 69.806, rel. Min. Celso de Mello; STJ, REsp nº 1.133.943, rel. Min. Felix Fischer). Consoante já se decidiu, "a apreensão de grande quantidade de drogas configura o animus de traficar, somente ilidível quando alegada a finalidade exclusiva de uso próprio, com robusto material probatório favorável ao mesmo" (STJ, Rec. Esp. nº 163.640, rel. Min. Jorge Scartezzini, apud Alberto Silva Franco e outros, Leis Penais Especiais e sua Interpretação Jurisprudencial, RT, vol. 2, 7ª edição, pág. 3190).

Nessa perspectiva, já decidiu o STJ: "Indicando a Corte local dar-se a condenação

não apenas pelo depoimento de policial, mas por outras provas também valoradas, não cabe a pretensão de nulidade da condenação. Inexistindo impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade. 3. Agravo regimental improvido" (AgRg nos EDcl no HC 446151 / RS, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA, Data do Julgamento 07/02/2019, Data da Publicação/Fonte DJe 27/02/2019).

Conclui-se, portanto, pelas circunstâncias da apreensão, notadamente a expressiva quantidade de drogas variadas apreendidas, parte delas já embaladas para o fornecimento a terceiros, além de vultosa quantia em dinheiro e acessórios para preparação de drogas, para posterior fornecimento a terceiros, tudo a indicar que seriam destinadas ao abastecimento do comércio espúrio.

Com relação à imputação pela prática do artigo 16, parágrafo único, inciso IV da Lei nº 10.826/03, observo que o caso dos altos se amolda ao artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03.

A autoria de Cyntia restou incontroversa, tendo os policiais localizado as munições apreendidas e periciadas em sua residência.

A materialidade é inconteste. Nesse sentido, conforme laudo de fls. 352/355, foram apreendidos "a) 07 (sete) cartuchos íntegros, de estojo e espoleta de aspecto externo dourado, dotados de projétil encamisado total ponta plana, portadores da marca e calibre "CBC40S&W NTA", exibindo os códigos de rastreamento, 01"APF37", 01"ASE92", 01"BBI57", 01"ACD60" e 02 sem código; b) 02 (dois) cartuchos íntegros, de estojo e espoleta de aspecto externo dourado, dotados de projétil encamisado expansivo ponta oca, portadores da marca e calibre "CBC40S&W", exibindo o código de rastreamento "ASE92"; c) 01 (um) cartucho íntegro, de estojo e espoleta de aspecto externo prateado, dotado de projétil encamisado total ponta plana, portador da marca e calibre "CCI40S&W NR"; d) 01 (um) cartucho íntegro, de estojo e espoleta de aspecto externo dourado, dotado de projétil semiencaimado ponta de chumbo, portador da marca e calibre " RP 30 REM".

Ainda, a potencialidade lesiva das munições foi devidamente constatada: "Quando dos ensaios de disparo da munição com armas de fogo de calibres compatíveis, todos os cartuchos foram submetidos ao teste de eficiência e funcionaram a contento, constatando-se assim a eficácia dos mesmos quanto à potencialidade lesiva da munição" (fls. 354).

Consigna-se, por oportuno, que a munição RP 30 REM é de uso restrito, consoante a Portaria nº 1.222/19, enquanto que as munições .40 (CBC40S&W NTA, CBC40S&W e CCI40S&W NR) são de uso permitido, nos termos da mesma portaria, sendo o caso de aplicação do princípio da consunção.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E DE USO PERMITIDO (ARTS. 12 E 16 DA LEI N. 10.826/03). ALEGADA AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE DE ESTAREM AS MUNIÇÕES ACOMPANHADAS DE ARMAMENTO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONFIGURAÇÃO.

Na esteira do entendimento desta Corte Superior, os crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/03 são de perigo abstrato, de modo que a potencialidade lesiva é presumida, não havendo necessidade, para a configuração do delito, de estarem as munições acompanhadas de arma de fogo.

DOSIMETRIA. APREENSÃO DE MUNIÇÕES DE DIFERENTES CALIBRES NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. APLICAÇÃO DA PENA RELATIVA AO CRIME MAIS GRAVE.

INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. Este Sodalício já se pronunciou no sentido de que a apreensão de armas ou munições de uso permitido e de uso restrito, no mesmo contexto fático, implica na caracterização de crime único por atingir apenas um bem jurídico, devendo ser aplicada somente a pena do crime mais grave.

2. Mais recentemente, porém, esta Corte Superior de Justiça vem entendendo que os tipos penais dos arts. 12 e 16, da Lei n. 10.826/03, tutelam bens jurídicos diversos e que, por tal razão, deve ser aplicado o concurso formal quando apreendidas armas ou munições de uso permitido e de uso restrito no mesmo contexto fático.

3. Na espécie, o Tribunal de origem manteve a tese aplicada pelo juízo primevo, no

sentido de que estaria caracterizado o crime único, tendo em vista que o apelo foi exclusivo da defesa, porém não deixou de observar, de maneira acertada, que o acusado foi beneficiado quanto à questão e que não seria cabível o pedido de aplicação da pena mais branda.

4. Agravo regimental improvido (AgRg nos EDcl no AREsp 1122758/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018)

Considerando que as munições foram apreendidas no mesmo contexto fático, de rigor a condenação da ré como incurso no artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03, a caracterizar hipótese de crime único.

Mérito em relação ao réu José Marcos

Com relação ao acusado José Marcos, entendo ser o caso de absolvição.

As provas produzidas no processo não são suficientes para proferir o édito condenatório do réu. Isso porque a única prova produzida nos autos de sua autoria é a sua declaração informal aos policiais de que trabalharia para a Cyntia, auxiliando-a no tráfico.

À exceção deste testemunho dos policiais que mencionam uma admissão meramente indireta, nada mais há nos autos que possa, com a segurança no processo penal, vincular o acusado com as drogas apreendidas no interior da residência da corré. Observo, por relevante, que a imputação envolve delitos de posse, que por sua natureza, exigem um maior cuidado do julgador na valoração probatória, especificamente na atribuição de vínculos daquele que se vê denunciado com os objetos ilícitos apreendidos, o que não parecer ser, pelo menos em relação ao réu José Carlos, a situação dos autos.

Diferentemente do que ocorre em relação à ré Cyntia, que, segundo as testemunhas policiais, indicou a eles o local de sua residência e, após o apoio com policiais e cães farejadores, foi apreendida significativa quantidade de drogas em sua casa, no que diz respeito ao corréu José Marcos, reforço que não há nenhum elemento de prova que permita concluir que aquela residência era também utilizada por ele. A sua vinculação com os ilícitos dar-se-ia, segundo a denúncia, por mera relação de trabalho informal com a acusada, o que me parece insuficiente, dadas as circunstâncias do flagrante, para fundamentar, tão somente por esse motivo, um decreto condenatório.

Assim, com relação ao réu José Marcos, parece-me adequada a solução absolutória, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Passo à fixação das penas com relação à ré CYNTIA

Crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, a pena base do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 deve ser fixada acima do mínimo legal, porque a quantidade expressiva e a variedade de substâncias entorpecentes são circunstâncias que implicam um maior potencial de lesão à saúde pública, traduzindo-se num mais elevado grau de culpabilidade da conduta. No caso concreto, a apreensão envolveu nada menos do que 1.745 (mil setecentos e quarenta e cinco) porções da substância vulgarmente conhecida por 'maconha', num total de 9.753,9g, uma sacola contendo cigarros artesanais de 'maconha' parcialmente queimados, pesando cerca de 22.7g, 3 (três) adesivos/selos contendo "LSD", num total de 0,04g, 2 (dois) comprimidos de ecstasy, num total de 0,8g, 1.462 (mil quatrocentos e sessenta e dois) porções de cocaína, num total de 715,9g, e 4 (quatro) sacos contendo cocaína a granel, num total de 1.767,8g. Ainda, atento ao art. 59, do Código Penal, verifico que a ré ostenta maus antecedentes (23ª Vara Criminal – Procedimento nº 0057614-90.2012.8.26.005, trânsito em julgado para a defesa em 28/03/2014, pena cumprida em 12/01/2015 - fls. 80 e 86/91). Ante essas circunstâncias desfavoráveis e valorando com preponderância o art. 42 da Lei 11.343/06, estabeleço a pena base em patamar intermediário, em 09 anos de reclusão e 900 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, ausentes causas agravantes e atenuantes da pena, mantenho a pena intermediária em 09 anos de reclusão e 900 dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria, não há causas de aumento de pena. Ante os maus

anteriores (específico - tráfico de drogas), não se aplica o redutor previsto no §4º. Pena em definitivo para este crime em 09 anos de reclusão e 900 dias-multa.

Crime do artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03

Na primeira fase de dosimetria, considero que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis à acusada: maus antecedentes - 23ª Vara Criminal - Procedimento nº 0057614-90.2012.8.26.005, trânsito em julgado para a defesa em 28/03/2014, pena cumprida em 12/01/2015 - fls. 80 e 86/91. Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 03 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, ausentes causas agravantes e atenuantes de pena, razão pela qual mantenho a pena, nesta segunda fase, em 03 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria, não há causas de aumento ou de diminuição da pena. Pena em definitivo para este crime em 03 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Nos termos do artigo 69, do Código Penal aplico o concurso material e torno a pena definitiva em 12 anos e 06 meses de reclusão e 911 dias-multa.

Dias-multa no mínimo legal.

Fixo o regime fechado para o início de cumprimento das penas privativas de liberdade, único adequado ao caso concreto, pelo quantum da pena atingida e ante os maus antecedentes da acusada, que já foi condenada anteriormente pela prática de tráfico de drogas.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão penal para:

- a) CONDENAR a ré CYNTIA RAMOS FONTES às penas de 09 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 911 dias-multa, esses no mínimo legal, pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06
- b) CONDENAR a ré CYNTIA RAMOS FONTES às penas de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 dias-multa, esses no mínimo legal, pela prática do crime descrito no artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03.

Praticados na forma do art. 69, CP, as penas privativas de liberdade perfazem 12 anos e 06 meses de reclusão e 911 dias-multa.

c) ABSOLVER o réu JOSÉ MARCOS DA SILVA FILHO da prática dos crimes imputados na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Consoante o art. 387, §2º, do CPP, mantenho o regime prisional acima fixado, pois inexistem informações sobre o comportamento carcerário da acusada para a progressão de regime, consoante o art. 112 da LEP. Nesse sentido: TJSP, 3ª Câmara Criminal, AC nº0045877-82.2014.8.26.0224, relator Desembargador Luiz Antonio Cardoso; TJSP, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, AC nº0004038-54.2014.8.26.0361, relator Desembargador Luiz Augusto de Sampaio Arruda.

Nos termos do §1º do art. 387 do Código de Processo Penal, considerando presentes os requisitos da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar da ré, ante a manifesta periculosidade que apresentam, sem prejuízo do conhecimento de eventual apelação a ser interposta. Recomende-se a ré no local em que se encontra presa. Tendo em vista a absolvição do corréu, expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de JOSÉ MARCOS DA SILVA FILHO.

Nos termos do artigo 63 e parágrafos da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do valor apreendido nos autos. Transitada em julgado a presente decisão, oficie-se à SENAD, observando-se o disposto no parágrafo 4º do dispositivo legal supracitado, para a adoção das providências cabíveis à espécie.

Determino a incineração das drogas e a destruição das munições apreendidas.

Após o trânsito, oficie-se ao TRE e IIRGD.

P.R.I.

São Paulo, 18 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA